Anderson Schreiber

Manual de Direito Civil Contemporâneo



A OBRA POSSUI VIDEOAULAS

3ª edição
revista e ampliada

saraiva jur

Capítulo 6

Direitos da Personalidade

SUMÁRIO: 1. Dignidade da pessoa humana. 2. Autonomia existencial. 3. O lançamento de anão. 4. Direitos da personalidade. 5. Características dos direitos da personalidade. 6. Autolimitação aos direitos da personalidade. 7. Direitos da personalidade no Código Civil de 2002. 8. Direito ao próprio corpo. 9. Mercado humano. 10. O caso Moore. 11. Exigência médica. 12. Cirurgias de transgenitalização. 13. *Wannabes.* 14. Consentimento informado. 15. Direito à privacidade. 16. Proteção de dados pessoais. 17. Direito ao nome. 18. Direito à identidade pessoal. 19. Direito à identidade pessoal das pessoas transgênero. 20. Direito à honra. 21. Direito de sátira. 22. Direito à imagem. 23. Colisão entre direitos da personalidade e liberdade de informação. 24. A questão das biografias. 25. Direito ao esquecimento. 26. Instrumentos de tutela da personalidade. 27. Tutela *post mortem* da personalidade. 28. A marcha infinita da personalidade.

1. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Duas guerras mundiais, os horrores do holocausto nazista e a efetiva utilização da bomba atômica foram apenas alguns dos assustadores acontecimentos que o mundo testemunhou no curto intervalo entre 1914 e 1945. Embora a História tenha conhecido massacres mais avassaladores, como a chamada "conquista" da América[141], nunca antes a repercussão de tais atrocidades provocara uma sensação tão generalizada de fragilidade. Em toda parte, despertaram os anseios por uma nova ordem de valores, apta a proteger a condição humana na sua redescoberta vulnerabilidade. Como explica Umberto Eco: "Foi neste século que se desenvolveu pela primeira vez uma solidariedade em escala planetária. Mesmo quando não a praticamos, sentimos que ela é um dever. (...) Outrora massacrava-se e não se sentia arrependimento"[142]. Laços de solidariedade formaram-se em torno do propósito maior de preservação da humanidade, preocupação que passaria a guiar os passos da comunidade jurídica internacional.

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, afirmaria expressamente que "o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo". A consagração da dignidade humana como "fundamento da liberdade" e valor central da ordem jurídica internacional influenciou as Constituições da segunda metade do século XX, que a incorporaram como verdadeira razão de ser do Estado Democrático de Direito. A Constituição brasileira a menciona já em seu art. 1º, entre os fundamentos da República: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)

III – a dignidade da pessoa humana.

No Brasil, como em diversos outros países, a dignidade humana assumiu posição de destaque no ordenamento jurídico[143]. Considerada como "princípio fundamental de que todos os demais princípios derivam e que norteia todas as regras jurídicas"[144], a dignidade humana tem sido o valor-guia de um processo de releitura dos variados setores do direito, que vão abandonando o liberalismo e o materialismo de outrora em favor da recuperação de uma abordagem mais humanista e mais solidária das relações jurídicas. Ao mesmo tempo, a visão cientificista do direito cede espaço a um viés mais principiológico e valorativo, que estimula o reenvio da solução dos casos concretos ao patamar mais elevado dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, a dignidade humana tem sido diretamente aplicada a um sem-número de casos concretos. Sua invocação tem se tornando cada vez mais frequente não apenas nos debates acadêmicos, mas também nas motivações das decisões judiciais, nas peças advocatícias, nas decisões administrativas, nos debates parlamentares, nas justificativas de projetos de lei e assim por diante.

Apesar disso, não é fácil definir a dignidade da pessoa humana. Poucas noções apresentam contornos tão fluidos. Sua longa trajetória filosófica não é unívoca, mas gravita sempre em torno da mesma ideia: a de que a espécie humana possui uma qualidade própria, que a torna merecedora de uma estima (*dignus*) única ou diferenciada. A dignidade humana não corresponde, portanto, a algum aspecto específico da condição humana, mas exprime, isto sim, "uma qualidade tida como inerente a todo e qualquer ser humano", sendo frequentemente apresentada como "o valor próprio que identifica o ser humano como tal"[145]. Seu conceito pode ser formulado nos seguintes termos: a dignidade humana é o valor-síntese que reúne as esferas essenciais de desenvolvimento e realização da pessoa humana. Seu conteúdo não pode ser descrito de modo rígido; deve ser apreendido por cada sociedade em cada momento histórico, considerando seu próprio substrato cultural.

O propósito da sua apreensão jurídica é assegurar proteção à condição

humana, em seus múltiplos aspectos e manifestações, tomando a pessoa "sempre como um fim e nunca como um meio"[146]. Nesse sentido é que se afirma ser contrário à dignidade humana "tudo aquilo que puder reduzir a pessoa (o sujeito de direitos) à condição de objeto"[147].

2. AUTONOMIA EXISTENCIAL

Isso não significa que a dignidade humana identifique-se com a liberdade individual, com a simples autonomia da vontade ou, ainda, com uma irrestrita autonomia existencial. A imensa maioria dos autores contemporâneos identificam na própria dignidade humana uma dimensão social, que autolimita a persecução de interesses existenciais quando possam, de algum modo, atentar contra a dignidade humana vista na perspectiva da relação entre o ser humano e o seu meio social. Assim, Luís Roberto Barroso, embora inserindo a autonomia individual no que denomina conteúdo intrínseco da dignidade humana, reconhece-lhe um "valor comunitário" que funcionaria como limite às escolhas individuais. Em suas palavras: O *valor comunitário* é o elemento social da dignidade humana, identificando a relação entre o indivíduo e o grupo. Nesta acepção, ela está ligada a valores compartilhados pela comunidade, assim como às responsabilidades e deveres de cada um. Vale dizer: a dignidade como valor comunitário funciona como um limite às escolhas individuais. Também referida como dignidade como heteronomia, ela se destina a promover objetivos sociais diversos, dentre os quais a proteção do indivíduo em relação a atos que possa praticar capazes de afetar a ele próprio (condutas autorreferentes), a proteção de direitos de outras pessoas e a proteção de valores sociais, dos ideais de *vida boa* de determinada comunidade. Para minimizar os riscos do moralismo e da tirania da maioria, a imposição de valores comunitários deverá levar em conta (a) a existência ou não de um direito fundamental em jogo, (b) a existência de consenso social forte em relação à questão e (c) a existência de risco efetivo para direitos de terceiros[148].

3. O LANÇAMENTO DE ANÃO

Esse embate entre diferentes aspectos da dignidade humana conduz frequentemente a casos concretos de difícil solução. Foi o que se viu, por exemplo, no caso do lançamento de anão. No entender do Conselho de Estado francês, aquela estranha prática reduzia o sujeito Manuel Wackenheim a objeto do lazer alheio, afrontando, desse modo, a sua dignidade humana. Cidadão francês, Manuel Wackenheim tem pouco mais de um metro e catorze centímetros de altura. O nanismo restringiu consideravelmente suas chances de emprego. No verão de 1991, passou a exercer, no interior da França, uma ocupação inusitada. Seu ofício consistia em se vestir com capacete e roupas acolchoadas, com alças nas costas, e ser lançado em direção a um colchão de ar por clientes de bares e discotecas. A competição, que ficou conhecida como *lancer de nain* (lançamento de anão), ganhou rápida popularidade e acabou por atrair a atenção das autoridades públicas francesas.

Em outubro daquele mesmo ano, o prefeito da cidade de Morsang-sur-Orge proibiu a realização da atividade. Manuel Wackenheim recorreu, então, à corte administrativa de Versailles, que anulou a proibição por considerar que não havia nenhum distúrbio à ordem, à segurança ou à saúde pública. O prefeito apelou da decisão e o Conselho de Estado francês acolheu o recurso, vedando a prática do lançamento de anão, por considerá-la uma afronta à dignidade humana. O caso ganhou repercussão internacional quando Wackenheim apresentou uma reclamação ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Sustentou, em síntese, que a proibição do Conselho de Estado francês, muito ao contrário de proteger, violava a sua dignidade humana, já que o impedia de exercer uma profissão. Alegou, ainda, que a decisão afrontava sua liberdade, sua privacidade e configurava ato discriminatório contra os portadores de nanismo. O Comitê considerou que a diferenciação, no caso, não configurava discriminação, já que decorria da

razão física de “os anões serem as únicas pessoas aptas a serem lançadas por outras”. Concluiu, ainda, que o banimento da atividade fora baseado em critérios objetivos e razoáveis, inexistindo violação aos direitos humanos[149].

A solução não é, naturalmente, imune a controvérsias. A dignidade humana não consiste em um conceito de aplicação matemática. A própria percepção do que é ou não é essencial ao ser humano varia conforme a cultura e a história de cada povo, e também de acordo com as concepções de vida de cada indivíduo. Tamanha fluidez não agrada aos juristas, sempre ansiosos por um porto seguro que permita distinguir o certo do errado, o lícito do ilícito, o legítimo do ilegítimo, dando alguma segurança e previsibilidade às soluções dos conflitos que possam surgir na vida social. Daí a necessidade tão sentida nos meios jurídicos de, sem rejeitar o caráter aberto da dignidade humana, indicar os principais atributos que a compõem e identificar as principais espécies de conflitos em que a dignidade humana entra em cena.

Daí o renovado interesse pelos direitos da personalidade na experiência jurídica contemporânea.

4. DIREITOS DA PERSONALIDADE

As primeiras construções em torno dos direitos da personalidade surgiram no contexto histórico da segunda metade do século XIX. A expressão foi concebida por jusnaturalistas franceses e alemães para designar certos direitos inerentes ao homem, tidos como preexistentes ao seu reconhecimento por parte do Estado, conforme esclarece De Ruggiero[150]. Eram, já então, direitos considerados essenciais à condição humana, direitos sem os quais "todos os outros direitos subjetivos perderiam qualquer interesse para o indivíduo, ao ponto de se chegar a dizer que, se não existissem, a pessoa não seria mais pessoa"[151].

Afirmava-se que os direitos da personalidade eram absolutos, imprescritíveis, inalienáveis e indisponíveis, características ainda hoje repetidas na legislação pátria e estrangeira.[152] A categoria abrangia um núcleo de atributos inseparáveis da pessoa humana, a ser protegido não apenas em face do Estado, mas também contra o avanço incessante da exploração do homem pelo homem. Domado o Leviatã, o direito se propunha agora a enfrentar o lobo. A luta, contudo, não foi fácil.

Os direitos da personalidade encontraram forte resistência em um ambiente jurídico ainda marcado pelo pensamento liberal, especialmente no campo do direito privado. Contribuiu também para isso a existência de divergências significativas entre os próprios defensores da categoria. Não havia, por exemplo, consenso sobre quais eram os direitos da personalidade. Falava-se com frequência no direito ao próprio corpo, no direito à honra e no direito à vida, mas alguns autores acrescentavam o direito ao nome e outros direitos. Havia mesmo quem incluísse no rol o direito à propriedade, cuja natureza patrimonial representava, para outros, a própria antítese dos direitos da personalidade. Para parte da doutrina, não havia ainda "direitos da personalidade" no plural, mas um único "direito geral da personalidade". Os desacordos, enfim, eram muitos.

Nesse cenário, não chega a ser espantoso que juristas importantes, como Savigny, Von Thur e Enneccerus, negassem qualquer validade científica à categoria. Viam nela uma inovação inconsistente. Sustentavam, em poucas palavras, que os direitos da personalidade configuravam uma contradição nos próprios termos, já que tinham como *objeto* o próprio *sujeito*. Se, para o direito civil, a personalidade consistia na capacidade de ter direitos, não podia essa mesma personalidade figurar como objeto de direito algum.

As críticas seriam, pouco a pouco, superadas. Estudos de relevo demonstrariam que a noção de personalidade deve ser considerada sob dois aspectos distintos. Sob o aspecto *subjetivo*, identifica-se com a capacidade que tem toda pessoa (física ou jurídica) de ser titular de direitos e obrigações. Sob o aspecto *objetivo*, contudo, "tem-se a personalidade como conjunto de características e atributos da pessoa humana, considerada como objeto de proteção por parte do ordenamento jurídico"[153]. Nesse último sentido é que se fala em direitos da personalidade.

Por muito tempo, contudo, as críticas aos direitos da personalidade minaram seu desenvolvimento. O Código Civil alemão, aprovado em 1896, não acolheu expressamente a categoria, frustrando os seus adeptos. O Código Civil brasileiro de 1916 também não trouxe nenhuma menção ao assunto. A omissão gerou efeitos desastrosos. As poucas alusões aos direitos da personalidade que existiam na nossa doutrina praticamente desapareceram da manualística nas décadas seguintes. O interesse pelo tema só voltaria a ser despertado entre nós a partir da segunda metade do século XX, com a consagração da dignidade humana no texto constitucional.

5. CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

É justamente em função do reconhecimento da intrínseca conexão entre a categoria dos direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, valor nuclear do ordenamento, que se reconhece a esses direitos uma série de características especiais, que conformam seu regime jurídico.

Em breve síntese, é possível reconhecer os seguintes atributos aos direitos da personalidade: (i) *extrapatrimonialidade*: são direitos cuja função é proteger a condição humana, em seus mais genuínos aspectos e manifestações, não sendo, portanto, suscetíveis de avaliação econômica, configurando situações jurídicas subjetivas existenciais; (ii) *generalidade*: sendo a dignidade valor reconhecido a todas as pessoas, a todos são assegurados os direitos voltados a promovê-la; (iii) *caráter absoluto*: sua observância se impõe a toda coletividade (*erga omnes*); (iv) *não taxatividade*: a ausência de previsão no Código Civil não impede que outras manifestações da personalidade humana sejam consideradas merecedoras de tutela, por força da aplicação direta do art. 1º, III, da Constituição (como os direitos à identidade pessoal, à integridade psíquica e à diferença, por exemplo)[154], característica por vezes referida como "elasticidade"[155]; (v) *imprescritibilidade*: podem ser exercitados a qualquer tempo, independentemente do decurso de longos prazos sem invocá-los[156]; (vi) *inalienabilidade, indisponibilidade e intransmissibilidade*: como manifestações essenciais da condição humana, os direitos da personalidade não podem ser alienados ou transmitidos a outrem, quer por ato entre vivos, quer em virtude da morte do seu titular, justificando a referência da doutrina a uma "titularidade orgânica", uma vez que as situações existenciais encontram sua razão de ser na realização do interesse do titular, sendo dele indissociável[157].

Embora não seja rara a afirmação de que "não pode o indivíduo autolimitar os direitos inerentes à sua personalidade"[158], a suposta irrenunciabilidade dos

direitos da personalidade é matéria que suscita intensa polêmica.

6. AUTOLIMITAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Um dos problemas mais palpitantes em matéria de direitos da personalidade diz respeito às autolimitações ao seu exercício. O Código Civil, em norma anacrônica, considera que os direitos da personalidade não podem no seu exercício "sofrer limitação voluntária". Nada mais distante da realidade, em que se sucedem cotidianamente contratos em que as pessoas concordam com certas limitações voluntárias ao exercício dos seus direitos da personalidade, como se vê nos contratos de licenciamento de uso de imagem celebrados por artistas e atletas, além de situações até mais extremas, como a dos contratos celebrados pelos participantes de *reality shows* como o *Big Brother Brasil*.

Eis um dos pontos mais difíceis da atual disciplina dos direitos da personalidade, ao qual o Código Civil deu tratamento intolerável, animando enunciado em sentido diametralmente oposto, aprovado já na I Jornada de Direito Civil: "O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral" (Enunciado n. 4). Isso, contudo, não basta: ao lado da duração e do alcance da autolimitação, cumpre também analisar a sua intensidade (grau de restrição que impõe ao exercício dos direitos da personalidade) e sua finalidade (que deve estar vinculada a um interesse direto e imediato do seu próprio titular).

Ainda não há consenso sobre os parâmetros que devem guiar o controle de legitimidade dessa limitação e só a análise específica de cada um dos atributos da personalidade humana contemplados pelo Código Civil pode oferecer auxílio nessa árdua tarefa.

7. DIREITOS DA PERSONALIDADE NO CÓDIGO CIVIL DE 2002

O Código Civil de 2002 passou a dedicar um capítulo aos direitos da personalidade em sua Parte Geral. Em tal capítulo, tratou a codificação dos seguintes direitos da personalidade: direito ao próprio corpo, direito ao nome, direito à honra, direito à imagem (embora apenas reflexamente) e direito à privacidade. A primeira advertência diz respeito ao caráter não taxativo do rol de direitos da personalidade contemplados pelo Código Civil. Trata-se apenas, como adverte Paulo Lôbo, daqueles direitos atinentes à personalidade humana "que produzem efeitos mais agudos nas relações civis"[159]. Há outros direitos da personalidade, como o direito à identidade pessoal, que não restaram contemplados expressamente no Código Civil.

Ainda de modo geral, pode-se afirmar que, embora o Código Civil tenha tido o mérito de tratar do tema, reservando-lhe capítulo autônomo na Parte Geral, o tratamento normativo dispensado aos direitos da personalidade pela nossa codificação é, em larga medida, insuficiente e anacrônico. De fato, o Código Civil brasileiro contempla os direitos da personalidade à imagem e semelhança do paradigma dos direitos subjetivos – o direito de propriedade, em orientação equivocada que já foi denunciada pela melhor doutrina[160]. Além disso, deixa de oferecer parâmetros ao intérprete para ponderações diante de outros interesses merecedores de tutela, preferindo soluções prontas e acabadas, de caráter puramente estrutural, que dificilmente se conformam à realidade concreta, como já se destacou em outra sede[161].

Tome-se como exemplo inicial o art. 13 da codificação, que contempla o chamado direito ao próprio corpo.

8. DIREITO AO PRÓPRIO CORPO

Ali, o legislador opta por critérios estruturais vedando, por exemplo, a diminuição física permanente (art. 13)[162]. Sugere, *a contrario sensu*, que a diminuição não permanente resta autorizada. Interpretando-se de modo literal o dispositivo, as inserções de microchips subcutâneos e outros mecanismos removíveis seriam considerados lícitos no direito brasileiro, mesmo que com finalidade puramente comercial (*v.g.*, controle de acesso de funcionários, como já se oferece no mercado dos Estados Unidos). Além disso, resta consagrada, por via indireta, a ideia de que as partes regeneráveis do corpo humano merecem menor proteção do que as irrecuperáveis, protegendo-se apenas estas últimas contra os impulsos da autonomia privada[163].

Tal concepção é perigosa e tem feito estrada especialmente no que diz respeito ao tratamento jurídico reservado às chamadas partes destacadas do corpo humano, como fio de cabelo, saliva, sêmen. Encaradas tradicionalmente como *res derelicta*, tais partículas carregam, hoje, a intimidade mais profunda da pessoa, representada pelo seu código genético. Em muitos países, tem-se chegado a declarar a extensão do conceito de corpo humano para assegurar sua proteção[164]. No Brasil, as próprias autoridades públicas têm perpetrado abusos, como revela o caso de Roberta Jamilly Martins Costa, cuja saliva coletada em guimbas de cigarros fumados na delegacia foi utilizada para realizar, contra a sua vontade, exame de DNA, que atestou a ausência de vínculo biológico entre ela e sua mãe de criação, acusada também do sequestro do menino Pedrinho[165]. Em outro caso amplamente noticiado, a cantora mexicana Gloria Trevi, após engravidar na Superintendência da Polícia Federal, teve sua placenta coletada e congelada para a realização de exame de DNA, contra sua expressa manifestação de vontade, tudo com a chancela do Supremo Tribunal Federal[166].

9. MERCADO HUMANO

Verifica-se, assim, a necessidade de se conferir adequada proteção, seja em face de terceiros, seja em face do próprio indivíduo, também às diminuições físicas não permanentes, cuja importância se intensifica em um cenário onde passam a servir, mais que à aferição da filiação biológica, a procedimentos de resultados verdadeiramente fantásticos como a fecundação *in vitro* e até mesmo a clonagem. O perigo de que, na ausência de uma firme proteção jurídica, o interesse comercial acabe por estimular a disposição de tais partículas aparece sob a forma de experiência consumada na América Latina, no nem sempre lembrado caso do Plasmaferesis, laboratório instalado na Nicarágua que coletava, mediante pagamento, o sangue de cidadãos pobres e subnutridos, além de prisioneiros e militares de baixo escalão "coagidos à doação". Com o integral apoio do governo ditatorial de Anastasio Somoza, o laboratório exportou, entre 1973 e 1977, para os Estados Unidos e a Europa, a cada ano, 300 mil frascos de sangue, despertando críticas do jornal de oposição, *La Prensa*, cujo diretor, Pedro Chamorro, acabou assassinado. O crime causou a indignação do povo nicaraguense, que tomou as ruas e, aos gritos de "Somoza vampiro!", queimou a sede do Plasmaferesis, derrubando o regime ditatorial, já minado pela revolta sandinista, e obrigando o ditador a fugir do país[167].

10. O CASO MOORE

Exemplo de consequências menos dramáticas, mas igualmente estarrecedor no que tange à exploração comercial de partes destacadas do corpo, tem-se no famoso caso Moore, em que células do sangue (linfócitos T) retiradas do baço extraído de um paciente afetado pela leucemia foram cultivadas e, por sua peculiar capacidade de produzir substâncias antibactericidas e antitumoriais, acabaram patenteadas pela University of California, dando margem a uma linha de produtos lançada no mercado farmacêutico. O paciente, Moore, homem de negócios do Alasca, propôs ação judicial reivindicando participação nos significativos lucros auferidos com a venda dos produtos pelos médicos, pesquisadores e empresas associadas. A jurisprudência norte-americana deu razão, inicialmente, ao paciente, mas, em última instância, a Suprema Corte da Califórnia decidiu que não lhe cabia nenhuma fatia na receita derivada do uso das células de Moore, já então avaliadas em mais de 3 milhões de dólares[168].

11. EXIGÊNCIA MÉDICA

Na esteira dos avanços recentes da genética e da biologia, casos semelhantes revelam, em todo o mundo, a temerária imissão de interesses comerciais no campo da disposição de partes destacadas do corpo, questão a que o Código Civil brasileiro não reservou a merecida atenção. Proibiu, como visto, a diminuição permanente da integridade física, deixando as demais hipóteses ao sabor da noção pouco precisa de bons costumes. Mesmo no que tange à diminuição física permanente, porém, o legislador de 2002 tem recebido críticas. Como única exceção à proibição de atos de disposição definitiva, o art. 13 do Código Civil indicou a "exigência médica". De pronto, o termo "exigência" sugere um rigor terapêutico nem sempre presente em intervenções socialmente aceitas e amplamente difundidas, como as cirurgias plásticas puramente embelezadoras e os tratamentos estéticos definitivos (depilação permanente etc.). Além de irreal, a exceção tem mérito discutível. A supervalorização do parâmetro médico pode estimular uma abordagem desfavorável de certas questões, como se vê, de forma emblemática, na evolução do tratamento reservado, no Brasil, às cirurgias de transgenitalização.

12. CIRURGIAS DE TRANSGENITALIZAÇÃO

As cirurgias de transgenitalização, ou de readequação de sexo, inicialmente vistas com desconfiança por parte dos tribunais, passaram a contar com um maior grau de aceitação baseadas na Resolução n. 1.652/2002 do Conselho Federal de Medicina, segundo a qual o "diagnóstico de disforia de gênero", caracterizado pelo "desconforto com o sexo anatômico natural" e pelo "desejo de mudar de sexo capaz de levar à automutilação ou auto-extermínio", é considerado idôneo a permitir ao médico a realização da cirurgia, atendidos os demais requisitos estabelecidos pela norma deontológica[169]. Assim, afirma-se que a qualificação do desconforto com o sexo natural como "disforia" e a consequente previsão das cirurgias de transgenitalização como tratamento adequado a estes "pacientes" atendem ao requisito da "exigência médica" previsto no art. 13 do Código Civil, de modo a autorizar a realização de tal procedimento cirúrgico. Sob um manto aparente benéfico, porque supera histórica resistência jurisprudencial à mudança de sexo[170], essa abordagem presta um desserviço evidente ao converter o debate – jurídico e ético – em torno da identidade de gênero em uma discussão puramente técnica, que reduz toda a imensa questão da autodeterminação corporal a um "tratamento" de enfermidade ou doença.

13. *WANNABES*

E se, no caso das cirurgias de readequação de sexo, o resultado útil alcançado pela abordagem médica – a autorização (Código Civil, art. 13 c/c Resolução CFM n. 1.652/2002) – pode justificar o efeito negativo do enfoque patológico adotado, outras hipóteses existem em que a conclusão médica caminhará em sentido diametralmente oposto. Comprova-o um sem-número de casos envolvendo os chamados *wannabes* ou *amputees-by-choice*, pessoas que se amputam por vontade própria, em atos que vêm preocupando a comunidade jurídica especialmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha[171]. Também nesse campo a medicina identifica distúrbios de adequação anatômica, associados ora à admiração pela capacidade de superação dos portadores de necessidades especiais, ora a um obsessivo anseio de especial atenção e cuidado que adviriam da mutilação[172]. No fim da década de 1990, o cirurgião Robert Smith amputou as pernas de dois pacientes fisicamente saudáveis, em um hospital na Escócia, suscitando o furor da imprensa britânica. Pois Smith alegou atender à "exigência médica" de encerrar o sofrimento daqueles pacientes que, segundo o cirurgião, se encontravam em um tal estado de desespero que seriam capazes de promover automutilação "em uma linha de trem" ou "utilizando armas de fogo", com sério risco de vida para si e para terceiros.

Vê-se que o critério da exigência médica, visto por juristas com certo temor reverencial, pode assumir, muitas vezes, contornos tão flexíveis quanto os que caracterizariam uma eventual alusão à exigência jurídica, com interpretações e nuances tão múltiplas quanto as que decorrem das próprias normas que procuram regular a dramática questão da disposição do próprio corpo. A verdade é que tais controvérsias encerram escolhas que não são biológicas, mas valorativas, para as quais um jurista não está, portanto, menos habilitado do que um clínico. E aqui, como em outros campos, se compreenderá que, se tal verdade, por ser apenas jurídica, não é verdade por

inteiro, tampouco o será a verdade médica. O melhor remédio há de surgir não da prevalência de uma sobre a outra, como sugere o art. 13 do Código Civil, mas da sua efetiva combinação.

14. CONSENTIMENTO INFORMADO

Há ainda equívoco grave no art. 15 do Código Civil – já examinado, ao se tratar, em capítulo anterior, do tema da interpretação das normas jurídicas. Ao afirmar que "ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica", o legislador sugere que, não havendo risco de vida, qualquer pessoa poderia ser constrangida a tratamentos médicos contrários à sua vontade. A regra de ouro aí, muito ao contrário, é a necessidade de consentimento informado[173]. Somente em casos excepcionalíssimos, resultantes da ponderação com outros interesses constitucionalmente protegidos, poderá haver a submissão de pessoa a tratamento médico compulsório. São exemplos a vacinação obrigatória e o tratamento médico de pessoa submetida por decisão judicial a medida de segurança, instituídos com foco na tutela do direito à saúde do próprio paciente e da coletividade.

15. DIREITO À PRIVACIDADE

Atualmente, é unânime na doutrina o entendimento de que a tutela da privacidade requer meios que transcendam a mera proteção negativa – não intromissão na vida privada, não obtenção de dados *etc.* –, exigindo, diante da inevitabilidade da coleta de dados pessoais, comportamentos positivos, que imponham a verificação de autenticidade das informações, sua correção, seu seguro armazenamento, sua utilização limitada à finalidade específica para a qual são fornecidos, sua avaliação não discriminatória *etc.*[174].

Em vez de se concentrar na pluralidade de remédios exigidos para a proteção da privacidade e dos dados pessoais, em face dessas novas controvérsias, o Código Civil de 2002 preferiu fazer constar de seu art. 21 o preceito simplista segundo o qual "a vida privada da pessoa natural é inviolável"[175]. Não é. A mera observação da vida cotidiana revela a violação sistemática da privacidade e, em alguns casos, justificadamente à luz da ordem jurídica. O passageiro compelido a permitir a inspeção de sua bagagem de mão pelo raio X de um aeroporto tem, inegavelmente, violada a sua privacidade, mas compreenderá facilmente que tal violação justifica-se, na situação concreta, pelo direito de todos os passageiros, inclusive o próprio, à segurança nos aviões. Todavia, se guardas do aeroporto de Miami decidem, como noticiou a imprensa, inspecionar os espaços internos do gesso que envolve o braço de uma menina brasileira de 9 anos, então, ter-se-á na esfera privada da criança uma interferência excessiva, abusiva.

Embora prosaicos, os exemplos revelam que a privacidade se sujeita, como outros interesses existenciais, a ponderações que, à luz das circunstâncias concretas, a fazem ora prevalecer, ora assentir com a prevalência de outros interesses que, também voltados à proteção da pessoa humana, se mostram dignos em abstrato de igual proteção. Também neste particular falhou, portanto, o legislador de 2002 ao declarar a tão solene quanto irreal inviolabilidade do direito à privacidade, quando melhor figura faria se

ocupando das múltiplas manifestações da privacidade, dos fatores relevantes para sua ponderação com outros interesses, ou ainda dos remédios específicos disponíveis à sua tutela.

A Constituição, nesse particular, tem a peculiar característica de ser mais específica que a codificação, chegando a detalhar instrumentos específicos de tutela da privacidade como o *habeas data*. A tradição inovadora inaugurada pela concepção do remédio heroico em pleno texto constitucional foi interrompida pelo Código Civil, que disciplinou a privacidade com olhos voltados para o passado, deixando sem resposta uma série de problemas debatidos na atualidade, como o direito à privacidade na internet e o direito à privacidade diante de controles biométricos para uso de serviços e ingresso em edifícios, inclusive edifícios públicos. Seguiram-se anos de espera até que o Congresso Nacional aprovasse a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018), que veio a transformar esse cenário.

16. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Como visto, a proteção dos dados referentes à pessoa humana consiste em um dos mais sensíveis desafios decorrentes do extraordinário avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas. A aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018) veio, enfim, inserir o Brasil entre os países que contam com instrumentos para a proteção desse importante aspecto do direito fundamental à privacidade. Fortemente influenciada pelo regramento europeu sobre a matéria, a Lei n. 13.709/2018 define *dados pessoais* de modo amplo, como "informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável" (art. 5º, I). Referida lei enumera, ainda, os princípios que devem reger as atividades de tratamento de dados, como boa-fé (objetiva), finalidade, adequação, transparência, entre outros (art. 6º). O que se exige, em apertada síntese, é que o tratamento de dados seja realizado sempre para propósitos compatíveis com a ordem jurídica, que os dados coletados sejam empregados exclusivamente nestas finalidades e que o tratamento se dê de modo seguro e transparente, garantindo a mais ampla proteção à pessoa humana.

Merece destaque o tratamento protetivo conferido aos chamados *dados sensíveis*, ou seja, dados pessoais sobre "origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural" (art. 5º, II). A definição legal não deve ser vista como taxativa, devendo a expressão *dado sensível* ser interpretada, a rigor, como qualquer informação relacionada a aspectos íntimos e existenciais da pessoa humana cuja divulgação possa atrair fundado risco sobre sua esfera jurídica. Daí por que o legislador, ao dispor sobre o tratamento dos dados sensíveis, exige consentimento do titular ou de seu responsável legal "de forma específica e destacada, para finalidades específicas", salvo nos casos em que o dado em questão for indispensável

para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; ou outros fins especificamente indicados pelo art. 11 da Lei n. 13.709/2018.

Cumpre registrar que a Lei n. 13.709/2018 foi aprovada com vetos, sendo o mais relevante deles aquele aposto à criação de agência reguladora com a atribuição precípua de zelar pela proteção dos dados pessoais. Como razão do veto, foi alegado vício de iniciativa. No ano seguinte, a Lei n. 13.853/2019 (fruto da conversão da Medida Provisória n. 869/2018) veio inserir na LGPD os arts. 55-A e seguintes, criando, enfim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A ANPD foi criada como "órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República" (art. 55-A, *caput*). Os §§ 1º e 2º do artigo 55-A esclarecem, porém, que tal natureza afigura-se transitória, podendo a Autoridade ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República, devendo tal transformação ser avaliada em até dois anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. A experiência de outros países mostra que a autonomia e a independência da Autoridade Fiscalizadora em relação ao Poder Executivo afiguram-se indispensáveis, pois o Poder Público, não raro, é um dos grandes violadores da privacidade dos cidadãos.

17. DIREITO AO NOME

Especial destaque reserva o Código Civil ao direito ao nome. Os arts. 16 e 18 cuidam do nome como direito, determinando, respectivamente, que "toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome", e que "sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial". A doutrina destaca que o nome consiste, a rigor, não em um direito, mas em verdadeiro direito-dever, na medida em que ninguém pode não ter um nome[176]. De uma tradição caracterizada pela imutabilidade do nome e por um forte controle estatal sobre suas alterações, herdada da experiência cultural portuguesa, o Brasil tem passado a um cenário mais dúctil, com uma sucessão impressionante de normas legais que vêm relativizar a inflexibilidade da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) para admitir novas hipóteses de alteração do nome, como a Lei n. 9.708/1998, que admite a substituição do prenome por apelidos públicos e notórios (Xuxa, Lula etc.), e a Lei n. 11.924/2009, que autoriza o enteado ou enteada a adotar o nome de família do padrasto ou madrasta (a chamada Lei Clodovil).

O nome deixa assim de ser uma imposição do destino, cuja alteração restava vedada pela ordem jurídica, para se tornar progressivamente um espaço de autonomia existencial da pessoa humana.

Reconhecendo a relevância do direito ao nome, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 2018, rejeitar pedido formulado por ex-marido para alteração do patronímico de ex-mulher, após o divórcio. Mesmo não tendo a ex-cônjuge apresentado defesa no processo, a Corte entendeu que "a pretensão de alteração do nome civil para exclusão do patronímico adotado por cônjuge por ocasião do casamento, por envolver modificação substancial em um direito da personalidade, é inadmissível quando ausentes quaisquer circunstâncias que justifiquem a alteração, especialmente quando o sobrenome se encontra incorporado e consolidado em virtude do uso

contínuo do patronímico pela ex-cônjuge por quase 35 anos”[177].

18. DIREITO À IDENTIDADE PESSOAL

"Uma das poucas coisas, antes talvez a única coisa que eu sabia ao certo era esta: que me chamava Mattia Pascal."[178] Inicia-se assim o célebre romance de Pirandello sobre o homem que, lendo no jornal a notícia equivocada da própria morte, decide passar a viver como alguém que não era, descobrindo-se, após um período inicial de satisfação, atormentado pela presença constante daquele que foi um dia. A frase inaugural da obra revela, com força literária, que o nome representa bem mais que o sinal de reconhecimento do seu titular pela sociedade: o nome estampa a própria identidade da pessoa humana.

Atenta a isso, a doutrina italiana desenvolveu, a partir da década de 1970, o chamado direito à identidade pessoal, que abrange a proteção ao nome, mas vai muito além, alcançando sua relação com os diferentes traços pelos quais a pessoa humana vem representada no meio social[179]. Trata-se, em outras palavras, de um "direito de 'ser si mesmo' (*diritto ad essere se stesso*), entendido este como o respeito à imagem da pessoa participante da vida em sociedade, com a aquisição de ideias e experiências pessoais, com as convicções ideológicas, religiosas, morais e sociais que diferenciam a pessoa e, ao mesmo tempo, a qualificam"[180].

Alguns autores entendem que a identidade pessoal integra o direito à privacidade, por contemplar, em última análise, a genuína relação entre a pessoa e seus dados pessoais. Outros autores preferem reservar lugar autônomo à identidade pessoal, quer pela sua aptidão a elevar a proteção do nome a patamar mais substancial que a tutela formalista que lhe vem tradicionalmente assegurada, quer pela peculiaridade dos instrumentos destinados à proteção da identidade pessoal, cuja inspiração é substancialmente diversa daqueles reservados à tutela da privacidade, ao menos em sua acepção original. Já se viu, contudo, que o direito à privacidade vem sendo tomado em acepção mais ampla que a simples tutela

da intimidade, para abranger o controle da captação e utilização de dados pessoais. Nessa concepção mais abrangente, a privacidade e a identidade pessoal aproximam-se de modo talvez indistinto. Seja como for, o importante é que se enfatize, dentro do âmbito de proteção à dignidade humana, esse fundamental aspecto da personalidade representado pela correta identificação do indivíduo no seu meio social.

19. DIREITO À IDENTIDADE PESSOAL DAS PESSOAS TRANSGÊNERO

Pessoas transgênero têm direito à identidade em conformidade com seu próprio gênero. Em julgamento histórico, o STF atribuiu interpretação conforme à Constituição ao art. 58 da Lei de Registro Públicos[181], para admitir a possibilidade de transgêneros alterarem seu nome e sexo (gênero) no registro civil, independentemente de se submeterem a cirurgia de transgenitalização ou a qualquer outro procedimento destinado a "readequar" seu próprio corpo ao sexo correspondente ao seu gênero (ADI 4.275)[182].

Com efeito, a função do registro civil é dar segurança à vida em sociedade. Um registro civil que atribua a uma pessoa atributos que ela não ostenta na vida social é um registro "falso", "errado", que exige retificação. Nome e gênero devem ser vistos não como estados registrais imutáveis ou verdades superiores ao seu titular, mas como um espaço essencial de realização da pessoa humana. O condicionamento da retificação à realização de procedimentos de adequação do sexo sobrepõe indevidamente uma suposta verdade biológica aos valores fundantes da ordem jurídica, calcados na dignidade humana. Como bem destacado por Luiz Edson Fachin, em sede doutrinária, "não parece adequado, dentro do ponto de vista constitucional da dignidade da pessoa humana, tornar a cirurgia condição *sine qua non* para a mudança de nome e sexo, pois, se assim fosse, de algum modo o sujeito sofreria uma violação a um direito. Se não aceitar realizar a cirurgia, terá seu direito ao nome e identidade negado, se fizer a cirurgia para que então possa ter reconhecido seu direito ao nome e sexo, terá seu direito ao corpo agredido. Uma análise sistemática da Constituição de 1988 dá conta de demonstrar que esse escambo entre direitos não parece ser a tônica que o constituinte pretendeu dar a lei fundamental"[183].

Na decisão da ADI 4.275, o STF não se limitou a extirpar a injustificável exigência de cirurgia. Afastou, ainda, a possibilidade de qualquer exigência

referente a idade, perícia médica ou outros limites que pudessem obstar a tutela do direito à identidade. Nessa esteira, a maioria da Corte concluiu ser desnecessário que o pedido de retificação fosse realizado pela via judicial, podendo ser apresentado diretamente em cartório. Ponderou-se que, na ausência de requisitos para a alteração, a atuação jurisdicional ficaria esvaziada, nada impedindo que o oficial do registro civil suscite o procedimento de dúvida, submetendo a apreciação da matéria a um magistrado. Assegurou-se, por fim, o sigilo em relação ao procedimento, de modo que os documentos retificados não podem fazer referência às alterações, expondo a intimidade da pessoa transgênero. Na esteira da decisão do STF, foi editado o Provimento n. 73/2018 do CNJ, que dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais, de modo a viabilizar o cumprimento da decisão.

20. DIREITO À HONRA

O direito à honra tutela o respeito à reputação da pessoa em seu meio social, e está contemplado no art. 17 do Código Civil, segundo o qual "o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória". Embora aluda ao uso do nome da pessoa, sua clara finalidade é evitar que ela seja exposta "ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória". O dispositivo não pode ser interpretado literalmente: a liberdade de informação, por exemplo, autoriza o uso de nome alheio para relatar fatos de interesse público e pode ocorrer que tais fatos, embora reflexo de uma situação verdadeira, acabem por expor a pessoa a desprezo público, como ocorre no caso das reportagens que denunciam situações de corrupção ou outros delitos. Também aqui o legislador parece ter optado por um enunciado normativo de aparência garantista e aplicação simples, mas não logrou solucionar diversos problemas que atinem ao direito à honra na atualidade.

Outro ponto importante atinente à honra diz respeito à distinção entre honra subjetiva – aquilo que diz respeito à percepção que a pessoa tem de si mesma – e honra objetiva – aquilo que diz respeito à percepção que a sociedade tem do indivíduo. A dicotomia de origem penal tem servido a embasar casos de indenização por dano moral à pessoa jurídica, por exemplo, com base em reportagens que relatam fatos falsos, afetando a reputação da pessoa jurídica na sociedade. A hipótese é controvertida. Para alguns autores, trata-se necessariamente de dano patrimonial, que afeta a atividade econômica da pessoa jurídica, ou do chamado dano institucional, quando se tratar de instituição sem fins lucrativos[184]. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, tem admitido a indenização por dano moral à pessoa jurídica, já consagrada na Súmula 227.

21. DIREITO DE SÁTIRA

Tema conexo ao direito à honra é o do direito de sátira, por vezes exercido com base na exposição da honra de certa pessoa. Exemplo emblemático tem-se no conhecido caso do Castelo de Itaipava, bela construção erguida pelo barão Smith de Vasconcellos na cidade fluminense de mesmo nome, e herdado por seus familiares. Em nítida galhofa com a revista *Caras*, que se utiliza de um castelo para divulgação do estilo de vida das celebridades, a revista humorística *Bundas* elegeu o Castelo de Itaipava como "Castelo de *Bundas*". A reportagem cômica informou, ainda, que a escolha daquele castelo era muito oportuna, já que o referido barão teria feito sua fortuna com os lucros advindos de uma fábrica de papel higiênico. Na sequência, "alegando apenas repetir uma piada recorrente à época da construção do castelo", a revista atribuiu-lhe o título de "Barão da Merda"[185]. Herdeiros do barão promoveram ação de indenização por danos morais em face da Editora Pererê, responsável pela veiculação da revista, que teria, na aludida matéria, exposto ao ridículo o nome do falecido e de sua família. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, onde foi vitorioso, por maioria, o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, que considerou inexistir dano à honra naquele caso concreto. Ponderou a necessidade de analisar a expressão supostamente injuriosa dentro do contexto de sua veiculação, em meio de comunicação explicitamente satírico, bem como o fato de o referido castelo ser mero instrumento da piada, e não o alvo dela, concluindo que a reportagem seria apenas "uma crítica genérica de costumes"[186].

Outra decisão importante nesse campo foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.451, declarou a inconstitucionalidade do art. 45, II, da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições), que vedava às emissoras de rádio e TV usarem "trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito".

Interpretado literalmente, o dispositivo serviria para proibir qualquer forma de crítica, especialmente aquela veiculada por meio do uso do humor, como acontece em charges ou sátiras, tão frequentes em nosso país, especialmente em época de eleições. Essa interpretação choca-se, todavia, com a Constituição da República, que garante as liberdades de expressão e informação como direitos fundamentais. O humor consiste em legítima manifestação da liberdade de expressão artística e intelectual, consagrada no art. 5º, IX, da Constituição. Atende, ainda, ao interesse de toda a sociedade, pois constitui instrumento importante de fomento à visão crítica, necessária à consolidação do Estado Democrático de Direito[187].

O confronto entre o direito de sátira e a tutela da honra é, naturalmente, delicado. Sua solução não está na prevalência abstrata de um interesse sobre outro, mas no sopesamento entre eles diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

22. DIREITO À IMAGEM

O direito à imagem exprime o controle que cada pessoa detém sobre sua representação externa, abrangendo qualquer tipo de reprodução de sua imagem ou de sua voz. O Código Civil, em momento infeliz, tratou da imagem conjuntamente com a honra (art. 20), deixando de reconhecer autonomia ao direito à imagem. De fato, uma interpretação literal do art. 20 sugere que uma pessoa somente poderia se insurgir contra os usos não autorizados da sua imagem se "lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais". A proteção da imagem ficaria, assim, dependendo da configuração de uma lesão à honra ou de uma finalidade comercial do uso da imagem. Muito ao contrário, nossa jurisprudência e doutrina já reconhecem, há muito, a autonomia do direito à imagem, como também o faz a própria Constituição da República (art. 5º, X). É nesse sentido que deve ser lida a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada em 2009, segundo a qual "independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais". Basta pensar no uso de imagem de pessoa famosa, sem autorização, em panfletos e materiais de campanha eleitoral para se perceber que o uso não autorizado da imagem de alguém pode ser impedido mesmo que não haja uso para fins comerciais ou uma lesão à reputação do titular da imagem.

O art. 20 do Código Civil incorre em um segundo equívoco grave: deixa de contemplar a frequente colisão entre direito à imagem e liberdade de informação, direito fundamental que mais comumente entra em choque com o direito à imagem. Na literalidade do art. 20, não seria possível divulgar a imagem de uma pessoa sem sua autorização, ainda que o fato retratado fosse verídico e houvesse legítimo interesse na circulação da informação no meio social, salvo no caso de ser necessária a divulgação à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. Por essa razão, alguns autores chegaram

mesmo a sustentar a inconstitucionalidade do art. 20 do Código Civil brasileiro, em face das liberdades de expressão e de informação, consagradas no art. 5º da Constituição[188]. Independentemente de se aderir ou não à tese da inconstitucionalidade do art. 20, o certo é que o Poder Judiciário deve, na análise dos casos envolvendo o uso indevido de imagem, avaliar se está diante de um legítimo exercício da liberdade de expressão ou de informação. Havendo, de um lado, legítimo exercício da liberdade de expressão ou informação e, de outro lado, uma ameaça ou lesão ao direito à imagem, competirá ao magistrado empregar a técnica da ponderação, a fim de verificar qual dos dois interesses deve prevalecer à luz das circunstâncias fáticas envolvidas.

Para auxiliar o Poder Judiciário nessa difícil tarefa, a melhor doutrina tem proposto parâmetros para tal ponderação, sustentando que o magistrado deverá atentar, por exemplo, para "a veracidade do fato"; "a licitude do meio empregado na obtenção da informação"; "a personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia"; "o local do fato"; "a natureza do fato" (fato que é notícia por si, como uma enchente ou uma eleição, ou que se torna notícia apenas por conta da pessoa envolvida); "a existência de interesse público na divulgação em tese"[189].

Em trabalhos específicos sobre o tema[190], tenho sustentado a necessidade de se abandonar alguns dos parâmetros tradicionalmente empregados na solução desses conflitos, em especial os parâmetros da "pessoa pública" e do "local público". Recuso, de plano, a qualificação de qualquer pessoa humana como "pública". Pessoas são *privadas* por definição. A expressão *pessoa pública* é empregada com o propósito de sugerir que o uso da imagem de celebridades dispensa autorização, pelo simples fato de que vivem de sua exposição na mídia. Pelo contrário, a proteção ao direito de imagem de celebridades é tão intensa quanto a de qualquer um. O fato de viverem profissionalmente de sua imagem na mídia só reforça a importância que a representação física assume em relação àquelas pessoas. O fato de a pessoa

retratada ser célebre ou notória pode, quando muito, sugerir que há algum grau de interesse do público em ter acesso à imagem, pela única razão de dizer respeito àquela pessoa. Isso não basta, contudo, para que se conclua pela prevalência da liberdade de informação sobre o direito à imagem. Diversos outros fatores devem ser sopesados antes de se concluir, no caso específico, qual dentre os dois direitos fundamentais há de prevalecer. Limitar-se ao critério simplista da “pessoa pública” é postura que incentiva perversas violações ao direito de imagem.

O mesmo ocorre com o parâmetro do “lugar público”. Nem toda imagem capturada em local de acesso público pode ser usada sem consentimento da pessoa retratada. É evidente que quem posa para uma foto na rua ou discursa em um palanque montado em uma praça pode ter sua imagem captada e transmitida dentro daquele contexto, mas isso ocorre em virtude do consentimento tácito que se extrai do comportamento do titular em tais situações. Se a imagem discrepa do consentimento tácito que se pode extrair da situação, como no caso da foto de famosa atriz cuja imagem foi captada por baixo do vestido, sem roupas íntimas, durante evento público de moda, parece evidente que não se pode considerar legítima a divulgação da imagem, por força da discrepância entre o suposto consentimento e aquilo que a imagem em si retrata, pouco importando aí se o lugar em que a imagem foi captada é ou não acessível ao público em geral.

23. COLISÃO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E LIBERDADE DE INFORMAÇÃO

A liberdade de informação – indevidamente chamada de “liberdade de imprensa”, pois não se trata de uma prerrogativa exclusiva de jornalistas ou entidades jornalísticas – caracteriza-se como direito de receber, acessar ou difundir informações. A liberdade de informação consiste em um direito fundamental na ordem jurídica brasileira. Sua importância, reconhecida pelo Constituinte, não diz respeito apenas ao campo das liberdades individuais, mas também ao interesse da sociedade como um todo. A liberdade de informação é indispensável, por exemplo, para a preservação da democracia.

Isso não significa dizer que a liberdade de informação seja uma liberdade absoluta ou ilimitada. A liberdade de informação subordina-se, em primeiro lugar, a um controle de legitimidade do seu exercício, fundado na veracidade da informação. Quem produz uma notícia falsa não exerce legitimamente a liberdade de informação. Incorre, ao contrário, em abuso do direito, que, como tal, não merece proteção. Essa é uma das razões pelas quais considero tecnicamente imprecisa a reunião da liberdade de expressão e da liberdade de informação sob o rótulo das “liberdades comunicativas”. A liberdade de informação dirige-se, por definição, a uma finalidade específica: informar a sociedade. Qualquer exercício da liberdade de informação que se distancie desse fim, desinformando a sociedade, perde seu merecimento de tutela.

Mesmo quando exercida de modo legítimo (ou seja, com o fim de informar), a liberdade de informação não assume caráter absoluto, não se podendo afirmar que sempre prevalecerá sobre outros direitos fundamentais, em especial os direitos da personalidade (honra, privacidade etc.). Em caso de colisão entre o legítimo exercício desses direitos e o legítimo exercício da liberdade de informação, deve-se recorrer, como já adiantado, à técnica da ponderação.

Cumpre registrar que, no Brasil, diversos autores têm sustentado o caráter

preferencial da liberdade de informação sobre os direitos da personalidade, à semelhança do que ocorre no direito norte-americano[191]. Discordo de tal posicionamento, defendendo a ausência de caráter preferencial da liberdade de informação, à semelhança do que ocorre no direito europeu. Os defensores do caráter preferencial baseiam-se, em resumo, nos seguintes argumentos: (a) superioridade da liberdade de informação, em interpretação histórica calcada no receio de censura estatal; (b) risco de acentuada imprevisibilidade que a ausência de caráter preferencial lançaria sobre a realização de reportagens jornalísticas, programas de TV, livros, entre outros; (c) indenização àquele que teve sua honra, imagem ou privacidade violada pelo titular da liberdade de informação já serviria de solução adequada para o problema.

Entendo, em primeiro lugar, que a Constituição brasileira, ao contrário do que ocorre no direito norte-americano, não admite hierarquização prévia ou preferência entre direitos fundamentais. Nosso texto constitucional tutela tanto a liberdade de informação quanto os múltiplos desdobramentos da dignidade humana como direitos fundamentais (honra, privacidade, imagem etc.) no mesmo dispositivo (art. 5º) em incisos que não apresentam qualquer forma de hierarquização. Aliás, se qualquer dos interesses em conflito devesse contar com uma preferência apriorística, a preferência seria seguramente dos direitos da personalidade, que representam direta e imediata manifestação da dignidade humana, contemplada como fundamento da República no art. 3º, III, do texto constitucional. A interpretação histórica não permite, a meu ver, que se inverta essa tábua axiológica definida textualmente pelo Constituinte.

Em segundo lugar, não concordo que a ponderação suscite risco de censura estatal ou de retorno ao autoritarismo. Não se pode, a meu ver, confundir o julgamento realizado pelo Poder Judiciário com as garantias processuais e materiais inerentes ao exercício da jurisdição, com censura, sob pena de se afastar qualquer espécie de controle de legitimidade sobre o exercício da liberdade de informação, que passaria a ser um “superdireito”. O alegado

risco de retorno ao autoritarismo surge, a meu ver, no outro lado do debate, quando se argumenta que o interesse da sociedade pela livre informação prevalece sobre interesses individuais, prevalência que se encontrava tipicamente presente no discurso dos regimes autoritários, que defendiam o coletivo como superior ao individual. Tratando-se de atributos essenciais da personalidade humana, ocorre justamente o oposto: o individual é que deve, salvo exceções muito específicas, prevalecer sobre o coletivo, a fim de se preservar efetivamente a esfera de autonomia existencial do ser humano, que não pode sofrer intervenções fundadas no suposto interesse coletivo[192]. Assim, se fosse possível, por interpretação da Constituição, extrair alguma preferência, haveria de ser necessariamente em favor da dignidade humana e de seus desdobramentos individuais, não já do interesse informativo da sociedade. Repito, contudo, que o texto constitucional tratou dos direitos da personalidade e da liberdade de informação como direitos de igual hierarquia, não sendo possível ao intérprete, a meu ver, extrair interpretativamente da nossa Constituição uma preferência *a priori* por qualquer dos interesses quando em colisão.

Em terceiro lugar, registro que a ausência de previsibilidade absoluta na solução desses conflitos acontece em qualquer hipótese de colisão de direitos fundamentais, não havendo nenhuma razão para que, nessa situação específica, isso seja obstáculo à aplicação da técnica da ponderação, já empregada em tantas matérias por nossas cortes, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, os casos de colisão entre liberdade de informação e outros direitos fundamentais têm chegado com frequência cada vez maior aos tribunais, inclusive ao STF, que tem tido, recorrentemente, a oportunidade de fixar parâmetros de ponderação, que poderiam funcionar como importante cartilha sobre os cuidados que devem ser adotados nas situações limítrofes, afastando, de tal modo, a imprevisibilidade sobre o resultado das ações adotadas pelos titulares da liberdade de informação em cada tipo de situação.

Por fim, a “solução” consubstanciada na oferta de indenização posterior

não é uma solução minimamente adequada. Deixar de impedir a conduta lesiva no momento em que ocorre contraria toda a evolução da responsabilidade civil contemporânea, que pretende prevenir os danos em vez de simplesmente indenizá-los pecuniariamente. A lesão a direitos da personalidade revela-se frequentemente irremediável, não se apagando com o recebimento de qualquer soma em dinheiro. A tese da indenização, note-se, não representa um "meio-termo" porque, em última análise, permite que a dignidade humana seja violada por quem quer que disponha de recursos para pagar o *preço da violação*. Ora, o que a Constituição brasileira assegura a todo cidadão não é (apenas) o direito a ser indenizado por violações à sua personalidade; são os direitos da personalidade em si. A indenização é um remédio subsidiário, para quando nada mais funciona. Não pode ser o remédio principal para a violação de um direito fundamental, protegido pelo Constituinte.

Ausente uma preferência apriorística e abstrata, diante de colisão entre a liberdade de informação e outros direitos fundamentais, cumpre ao intérprete aplicar o método da ponderação. Assim, deve-se resistir à tentação de traçar parâmetros supostamente aplicáveis a todos os casos em que se contraponham direitos da personalidade e liberdade de informação. Cada tipo de situação fática apresenta circunstâncias relevantes distintas, conforme os diversos interesses que se conjugam concretamente. Por mais fácil que pareça o caminho da hierarquização prévia, da criação de "superdireitos" ou "direitos preferenciais", não se pode nem se deve renunciar ao exercício da ponderação entre os interesses em conflito – mesmo que tal exercício seja mais delicado e mais difícil sob o ponto de vista técnico. O que se deve fazer, a meu ver, é, considerando as hipóteses mais frequentes de colisão, elaborar parâmetros que forneçam grau satisfatório de previsibilidade e uniformidade às decisões judiciais eventualmente proferidas sobre o tema.

Essa foi a orientação acolhida na *VIII Jornada de Direito Civil* promovida pelo Centro de Estudos da Justiça Federal, em que restou aprovado o

Enunciado n. 613, segundo o qual “a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro”.

24. A QUESTÃO DAS BIOGRAFIAS

Um amplo debate nacional foi travado em torno do tema das "biografias não autorizadas", ou seja, biografias que não contavam com a prévia autorização do biografado. Tornou-se célebre no Brasil o caso da biografia do cantor Roberto Carlos, que propôs processos cível e criminal contra a editora da obra e o biógrafo por conta do seu descontentamento com a exposição no livro de detalhes delicados de sua vida pessoal, como o falecimento de sua esposa e o acidente que lhe tolheu a perna. As ações foram encerradas por meio de um acordo, mas deflagraram amplo debate nacional, que culminou com a propositura da ADI pela Associação Brasileira de Editores de Livros e seu julgamento no STF.

Outro caso célebre foi o da biografia de Manoel dos Santos, o Mané Garrincha, tema do livro *A estrela solitária*, de Ruy Castro, que, no entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não se limitou "a relatar o futebol de Garrincha, a habilidade que o tornou um mito mundial, suas proezas nos gramados e vitórias nos campeonatos; infelizmente foi muito além, invadindo a intimidade do cidadão Manoel dos Santos e apequenando a sua imagem... Nem mesmo a intimidade de sua vida familiar foi poupada"[193]. A invasão da privacidade, identificada pela corte, não foi invocada pelo já falecido gênio das pernas tortas, mas por suas filhas, segundo as quais a obra "agride com tamanha violência a intimidade do ídolo mundial" que chega a descrever "de modo chulo" as "particularidades físicas da genitália de Garrincha, tudo isso com o objetivo de tornar atraente o livro e alcançar o lucro objetivado pela ré (editora) e seus sócios nessa lamentável empreitada"[194].

Merece destaque, ainda, o caso envolvendo a biografia de Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro conhecido como Lampião, escrita pelo juiz aposentado Pedro de Moraes Silva e intitulada *Lampião – o Mata Sete*, na qual o autor, além de narrar a carreira criminosa do biografado, teria exposto

sua intimidade ao afirmar que o cangaceiro teria sido homossexual. A obra também relata a suposta prática de infidelidades por parte de Maria Bonita, mulher de Lampião, além de questionar a real paternidade da filha do casal, levando esta a ajuizar ação judicial pleiteando a proibição da circulação do livro. A demandante obteve êxito na primeira instância. O juiz sentenciante entendeu que "não se admite assim que o requerido tente passar a ideia, através de sua obra, de que Lampião era homossexual, pois tal comportamento, a toda evidência, não é compatível com a história de vida de Lampião e muito menos com a história do cangaço". Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe reformou a sentença, invocando a vedação constitucional à censura e assentando que "afirmar a homossexualidade de um homem público, nos tempos modernos, ainda que tal figura seja símbolo da masculinidade de uma época, não configura qualquer demérito ou agressão moral"[195].

Esses e outros casos acumularam-se na experiência jurisprudencial brasileira e acabaram dando ensejo à ADI 4.815, julgada em 2015 pelo STF, que deu interpretação conforme a Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, a fim de declarar inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias[196]. A exigência de autorização prévia foi considerada inconstitucional justamente por fazer com que o direito à privacidade prevalecesse, *a priori* e em abstrato, sobre a liberdade de expressão.

A associação autora da ADI pretendia, ainda, ver reconhecida a impossibilidade de proibição de circulação de livros em razão da tutela da honra ou da privacidade do biografado, o que não restou expressamente acolhido pela Corte. Ainda que alguns Ministros revelem adotar o entendimento segundo o qual a liberdade de expressão goza de proteção preferencial em relação aos direitos da personalidade – na esteira da posição norte-americana sobre o tema –, a Corte não se definiu a respeito disso. Com efeito, a tese de que uma biografia pode tratar de todo e qualquer aspecto da vida privada do biografado, sendo eventuais conflitos resolvidos por meio de

indenização posterior ao biografado, é uma tese inconstitucional, pois faz com que a liberdade de expressão prevaleça *a priori* e em abstrato sobre a privacidade[197].

25. DIREITO AO ESQUECIMENTO

Sempre associado ao direito à privacidade, o chamado *direito ao esquecimento* tem ganhado destaque na mídia. O nome "direito ao esquecimento" induz em erro: não se trata de exigir o esquecimento de fatos pretéritos nem de apagar o passado ou reescrever a História. O direito ao esquecimento deve ser visto não como direito a eliminar dados históricos (o nome esquecimento é, por isso mesmo, a rigor, impróprio), mas como direito da pessoa humana de se defender contra uma *recordação opressiva de fatos pretéritos* que podem minar a construção e reconstrução da sua identidade pessoal, apresentando-a à sociedade sob falsas luzes (*sotto falsa luce*)[198], de modo a fornecer ao público uma projeção do ser humano que não corresponde à sua realidade atual.

Tecnicamente, o direito ao esquecimento é, portanto, um direito (a) exercido necessariamente por uma pessoa humana; (b) em face de agentes públicos ou privados que tenham a aptidão fática de promover representações daquela pessoa sobre a esfera pública (opinião social), incluindo veículos de imprensa, emissoras de TV, fornecedores de serviços de busca na internet etc.; (c) em oposição a uma recordação opressiva dos fatos, assim entendida a recordação que se caracteriza, a um só tempo, por ser desatual e recair sobre aspecto sensível da personalidade, comprometendo a plena realização da identidade daquela pessoa humana, ao apresentá-la sob falsas luzes à sociedade.

Originário do *diritto all'oblio*, da experiência jurídica italiana, o direito ao esquecimento nasce no campo da ressocialização de ex-detentos, que não devem ser permanentemente identificados como tais, sob pena de se impedir seu efetivo retorno à vida em sociedade. No Brasil, porém, a interpretação que lhe foi conferida pelo Superior Tribunal de Justiça como um "um direito de não ser lembrado contra sua vontade"[199] acaba por convertê-lo em verdadeiro direito de propriedade sobre os acontecimentos pretéritos, caindo

no equívoco já denunciado neste capítulo de aplicar aos direitos da personalidade a lógica proprietária[200]. A ampla aplicabilidade do direito ao esquecimento ao campo da internet tem suscitado renovado interesse nos últimos anos[201].

Nesse campo, é possível delinear, de forma geral, três correntes doutrinárias: (i) *pró-informação*: simplesmente não existe um direito ao esquecimento, que, além de não constar expressamente da legislação brasileira, não poderia ser extraído de qualquer direito fundamental nem mesmo do direito à privacidade e à intimidade. Um direito ao esquecimento seria, ademais, contrário à memória de um povo e à própria História da sociedade. A liberdade de informação prevaleceria sempre e *a priori*; (ii) *pró-esquecimento*: o direito ao esquecimento não apenas existe, como deve preponderar sempre, como expressão do direito da pessoa humana à reserva, à intimidade e à privacidade. Na esteira da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana – valor supremo na ordem constitucional brasileira –, esses direitos prevaleceriam sobre a liberdade de informação acerca de fatos pretéritos, não atuais. Entender o contrário seria rotular o indivíduo, aplicando "penas perpétuas" por meio da mídia e da internet; (iii) *intermediária*: a Constituição brasileira não permite hierarquização prévia e abstrata entre liberdade de informação e privacidade (da qual o direito ao esquecimento seria um desdobramento). Figurando ambos como direitos fundamentais, não haveria outra solução tecnicamente viável que não a aplicação do método de ponderação, com vistas à obtenção do menor sacrifício possível para cada um dos interesses em colisão. Esta última posição é que nos parece mais adequada[202].

A matéria aguarda posicionamento do Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.010.606/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. O tema, bem ou mal posto, tangencia diversas outras questões polêmicas, como a indexação de resultados por motores de busca da internet, a tutela *post mortem* do direito à imagem, entre outras.

	Detalhes sobre o direito ao esquecimento. O autor analisará as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e o julgamento em curso perante o Supremo Tribunal Federal, considerando as diferentes posições sobre o tema. Acesse também pelo *link*: https://somos.in/MDCC203	

26. INSTRUMENTOS DE TUTELA DA PERSONALIDADE

O debate em torno dos remédios cabíveis evidencia a insuficiência das técnicas ressarcitória e repressiva, calcadas no binômio lesão-sanção, para propiciar a proteção integral que se deve dispensar à dignidade humana[203]. O art. 12 do Código Civil, ao proclamar que "pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei", reforça os mecanismos de proteção no momento patológico da violação[204]. Não é, ainda, suficiente. Aos direitos da personalidade deve se reconhecer "uma tutela complexa, que se transmuda diante das necessidades do caso concreto, sobretudo, porque constatamos que a personalidade humana possui desdobramentos que apenas se revelam na medida em que certas necessidades sociais se estabelecem, de maneira a tornar impossível um esgotamento apriorístico e fechado de suas hipóteses por parte da ordem jurídica"[205]. É papel do intérprete extrair do ordenamento meios adequados não só para proteger a pessoa humana, mas também para, na medida do possível, promover a sua dignidade.

27. TUTELA ***POST MORTEM*** DA PERSONALIDADE

Cabe, por fim, indagar como reage o ordenamento jurídico ao fato de alguém atentar contra os direitos da personalidade de pessoa já falecida. Por exemplo, o que ocorre se alguém publica uma notícia falsa, atribuindo a pessoa morta uma conduta reprovável ou até mesmo a prática de um delito? Não há dúvida de que, com a morte, a personalidade em sentido subjetivo (aptidão para adquirir direitos e obrigações) se extingue. A própria existência da pessoa cessa[206]. Mas o que ocorre com a personalidade em sentido objetivo, assim entendido o conjunto de atributos essenciais da pessoa humana? Extingue-se com a pessoa? Se não se extingue, tampouco se transmite a quem quer que seja, já que é intransmissível por definição. A ofensa fica, então, sem consequência?

O problema é tecnicamente delicado, mas o Código Civil, em boa hora, reservou-lhe uma solução prática. O parágrafo único do art. 12 ocupou-se do tema, atribuindo aos herdeiros legitimação para requerer medidas destinadas a fazer cessar a lesão ou ameaça aos direitos da personalidade do morto[207].

Não se trata de uma concessão fantasmagórica, mas de norma ditada pelo interesse social. Os direitos da personalidade projetam-se para além da vida do seu titular. O atentado à honra do morto não repercute, por óbvio, sobre a pessoa já falecida, mas produz efeitos no meio social. Deixar sem consequência uma violação desse direito poderia não apenas causar conflitos com familiares e admiradores do morto, mas também contribuir para um ambiente de baixa efetividade dos direitos da personalidade. O direito quer justamente o contrário: proteção máxima para os atributos essenciais à condição humana. Daí a necessidade de se proteger *post mortem* a personalidade, como valor objetivo, reservando a outras pessoas uma extraordinária legitimidade para pleitear a adoção das medidas necessárias a inibir, interromper ou remediar a violação, como autoriza o art. 12 do Código Civil.

Instigante caso de tutela *post mortem* dos direitos da personalidade foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2019: após o falecimento do pai, suas três filhas entraram em conflito em relação à destinação do cadáver do genitor, que, em vida, não havia definido o destino a ser dado a seu corpo. A filha caçula, que morava com o pai, adotou as providências para submeter o corpo a criogenia. As filhas mais velhas do *de cujus*, no entanto, discordaram da providência adotada pela caçula e ajuizaram ação pleiteando a obtenção de alvará para sepultar o corpo do pai. Após variados entendimentos nos julgamentos em primeira e segunda instâncias, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o chamado *direito ao cadáver* como um desdobramento dos direitos da personalidade de cada indivíduo, de modo que, transcendendo a discussão entre as filhas, procurou reconstruir a vontade do próprio de cujus no caso concreto. Nessa esteira, concluiu o STJ, após a análise de diferentes elementos da demanda, que a manifestação da filha mais nova *"é a que traduz a real vontade de seu genitor em relação à destinação de seus restos mortais, visto que, sem dúvida alguma, é a que melhor pode revelar suas convicções e desejos, em razão da longa convivência com ele, que perdurou até o final de sua vida."*[208] Em especial, reconheceu o STJ que a autodeterminação pessoal não cessa com a morte, não podendo a vontade do titular ser afastada pelo interesse dos familiares simplesmente pelo fato de ter falecido. Impõe-se, portanto, o respeito às decisões adotadas explícita ou implicitamente em vida acerca da destinação do próprio corpo após a morte, desde que tais decisões se revelem compatíveis com a ordem constitucional.[209]

28. A MARCHA INFINITA DA PERSONALIDADE

Os direitos da personalidade desafiam as classificações e taxonomias a que tanto se apegaram os juristas em um passado recente. A história mostra o fracasso de todas as tentativas de enumerar os direitos da personalidade em um rol definitivo. Concluiu-se, enfim, que não são *numerus clausus*, ou seja, de número fechado. Como atributos considerados essenciais à condição humana, sua compreensão e amplitude variam no tempo e no espaço. O caráter aberto da dignidade humana não permite o congelamento das suas múltiplas expressões. Da prática judicial, da produção legislativa, da reflexão doutrinária emergem, a cada dia, novos direitos da personalidade, manifestações existenciais as mais variadas que vêm clamar pelo reconhecimento de sua essencialidade. A própria distinção entre essas expressões não é rígida. Muitos conflitos concretos envolvem, a um só tempo, a violação do direito ao nome, do direito à imagem, do direito à privacidade, dentre outros. O que resta atingido, em última análise, é a dignidade humana. A construção dos direitos da personalidade como uma categoria geral tem a utilidade de evidenciar, para fins práticos, as semelhanças e as diferenças entre os vários atributos da condição humana, sem ameaçar a indelével unidade que os vincula, como aspectos de um todo indivisível.

	Análise de direitos da personalidade não reconhecidos de forma expressa no Código Civil. O autor discutirá casos recentes e polêmicos, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo projeções dos direitos da personalidade na vida contemporânea. Acesse também pelo *link*: https://somos.in/MDCC204	